

1501268-44.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 15ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE BANDEIRA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JOSE BANDEIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, pois segundo apurado no dia 14 de janeiro de 2022, por volta ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

15ª Vara Criminal

Rua Dr. Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1501268-44.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501268-44.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JOSE BANDEIRA DA COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Elaine Cristina Pulcineli Vieira Gonçalves

Vistos.

JOSE BANDEIRA DA COSTA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, pois segundo apurado no dia 14 de janeiro de 2022, por volta das 18h15min, em período de calamidade pública (Decreto Estadual 64.879, de 20/03/2020), na Praça Júlio Prestes, 1, - República, nesta cidade e comarca, JOSE BANDEIRA DA COSTA, qualificado às fls. 18, trazia consigo 93 porções de cocaína - totalizando 64,9 gramas, para fins de fornecimento a terceiros e sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A denúncia foi recebida, o réu foi citado e notificado, apresentando resposta à acusação.

Após, a manutenção do recebimento da denúncia, em sede de audiência de instrução, debates e julgamento, foram ouvidos dois guardas civis metropolitanos e o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução criminal, o Ministério Público pugnou pela condenação do réu nos exatos termos da denúncia.

Já a Defesa pleiteou, em suma, pela absolvição do réu por insuficiência probatória e em caso de eventual condenação pela fixação de regime de cumprimento de pena em regime diverso do fechado, com aplicação do art. 387, §2º, do CPP, pela aplicação do disposto no §4º do art. 33, da lei de drogas, bem como possibilidade de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade do delito em questão restou comprovada pelo boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão das drogas, laudo pericial de fls. 118/120, com resultado POSITIVO para cocaína.

A autoria também é inconteste.

O próprio réu ao ser interrogado nesta data, confirmou que estava devendo para um traficante e assim aceitou passar com algumas porções de cocaína, escondidas em suas partes íntimas, para assim conseguir dinheiro e saldar sua dívida.

A confissão do acusado, ao contrário do alegado pela combativa Defesa foi devidamente corroborada por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório.

Com efeito, os dois guardas civis metropolitanos ouvidos nesta data foram unânimes em afirmar que estavam na região da Cracolândia e próximo ao "fluxo" visualizaram o réu em atitude suspeita, correndo e olhando para trás e diante disso conseguiram aborda-lo, e em revista pessoal, com ele foram encontrados em suas partes íntimas, aproximadamente 100 porções de cocaína e diante disso ele foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia Local para a lavratura do boletim de ocorrência.

É de asseverar, ainda, que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem guardas civis metropolitanos, nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas, mesmo que não tenham sido arroladas outras testemunhas.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de agentes de segurança pública e aqui considerados os Guardas Civis Metropolitanos em uma interpretação extensiva, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados, em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei.

De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento. A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser comprovado nestes autos, muito pelo contrário a narrativas dos dois policiais foi devidamente confirmada pelo próprio autor do crime o que reforça ainda mais a posição adotada por esta magistrada e pela maioria esmagadora da doutrina e jurisprudência.

Ressalte-se que não há nos autos indício que qualquer tipo de perseguição contra o acusado, ao contrário, o próprio réu confessou a prática do crime e praticamente narrou os fatos de forma idêntica a relata pelas testemunhas ouvidas, fato este que confirma que a posição desta magistrada e acima citada é a que deve ser adotada, sem quaisquer reservas.

Por conseguinte, é idônea a prova oral produzida pela acusação.

Caracterizada, portanto, a infração penal a condenação é medida que se impõe. Dessa forma, passo a dosar a pena. O réu é reincidente específico, tendo sido condenado definitivamente por crime de tráfico, consoante certidão de fls. 32/33, que transitou em julgado para a Defesa consoante pesquisa realizada nesta data nos autos originários 0107226-21.2017.8.26.0050, que tramitou perante a 18ª Vara Criminal Central, perante o sistema "e-saj", o que será levado em consideração na segunda fase da aplicação da pena.

Não possui outros antecedentes criminais e assim sendo a pena base será fixada no mínimo legal de 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Na segunda fase, considerando a reincidência específica a pena deve ser ainda aumentada em mais 1/6, chegando-se ao patamar de 5 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Também presente no caso a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "j" e a atenuante da confissão e assim a pena não será alterada.

Apenas a título de argumentação, ressalta-se que o crime foi cometido em situação de calamidade pública tendo em vista a pandemia que assola o país por conta do coronavírus - COVID-19, reconhecida por meio do Decreto nº 64.879/2020 de 20/03/2020. Ademais, respeitadas posições em contrário, para esta magistrada, o estado de calamidade pública acabou por facilitar a execução de crimes, ainda mais diante da necessidade de isolamento social a fim de retardar a propagação da doença, o que gerou a redução de pessoas e policiais nas ruas, defasando a vigilância estatal. Veja-se que na época destes fatos, havia recém-chegado ao Brasil uma nova variante denominada "Ômicron" que estava causando a morte de inúmeras pessoas.

Na terceira fase, há prova de que o réu é reincidente específico. Portanto, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, não há que reduzir a pena do acusado.

Neste ponto, não há que se falar na ocorrência de bis in idem ao se considerar a reincidência para agravar a pena e, ao depois, negar a aplicação do redutor previsto no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06, pois, conforme já decidido, "...na aplicação do preceito em foco, o Juiz há de verificar, também, a culpabilidade do agente e as circunstâncias do crime, sem o que estará ferindo o princípio da individualização da pena, não se podendo falar em bis in idem por ter sido a reincidência considerada para aumentar as sanções e também impedir a incidência do redutor do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, pois a aplicação de tal dispositivo exige a ocorrência simultânea de todas as condições mencionadas, ou seja, ser o agente primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividade criminosa e nem integrar organização criminosa, o que não é o caso do acusado.

Conforme já decidiu o Egrégio Superior Tribunal de Justiça a respeito do tema, "não há que se falar em bis in idem mas sim em cumprimento dos efeitos lógicos, legalmente previstos, decorrentes de um mesmo instituto jurídico a reincidência quando foi agravada a sanção do paciente na segunda etapa da dosimetria, dado o reconhecimento da agravante do art. 61 do CP, e deixou-se de fazer incidir a causa especial de diminuição da pena inserta no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão da não primariedade do paciente" (HC 118403/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 15.12.2009)." (Apel. Crim. Nº 990.10.184009-0, 5ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Tristão Ribeiro).

Outrossim, "O agravamento da pena pela reincidência também está correto e decorre de expressa determinação legal. Não ocorreu bis in idem. Não é raro que uma mesma circunstância reflita em mais de uma direção. O reincidente, v.g., não tem direito a sursis, por expressa disposição legal. Não obstante, o magistrado é obrigado a exacerbar sua pena, porque a reincidência também é agravante. Seguindo o mesmo raciocínio, no caso ora em exame, não aplicável a causa de redução de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, dada a recidiva, a qual também é usada para agravar a pena, por determinação legal." (Rev.

Crim. NCrim. Nº 990.09.160794-0, 6º Grupo de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, Rel. Des. Eduardo Pereira).

No mesmo sentido é a Jurisprudência dos Tribunais Superiores:

"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA.

INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE

SEGUIMENTO. TRÁFICO DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MINORANTE

AFASTADA. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DA JURISDIÇÃO ANTECEDENTE. SUPRESSÃO DE

INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a

infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A

causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades

criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que aplica a agravante de reincidência e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por ausência de atendimento aos requisitos para a aplicação da privilegiadora. 4. Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que as instâncias antecedentes não examinaram a matéria objeto da irresignação, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância. 5. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 191.580 2ª Turma do STF Rel. Min. Edson Fachin j. 16/11/2020).

"AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VEDADO REEXAME DA MATÉRIA FÁTICOPROBATÓRIA. CONFISSÃO PARCIAL NÃO UTILIZADA PARA A FORMAÇÃO DA CONVICÇÃO DO MAGISTRADO. MINORANTE DO § 4º NÃO APLICADA EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 3. A não aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06 não configura bis in idem. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido" (AgRg no HC 558867/SP 5ª Turma do STJ Rel. Min. Joel Ilan Parcionik j. 02/2/2021).

Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal que a Justiça Pública move contra o réu para CONDENÁ-LO à pena de 05 anos, 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, calculados na base do valor unitário mínimo, por estar incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.

Nos termos do art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, bem como em face da reincidência, o réu cumprirá a pena em regime inicial fechado. Não há que se falar em detração da pena para a fixação de início de cumprimento de pena, notadamente porque o réu sequer cumpriu o requisito objetivo previsto em lei para ser beneficiado, ou contrário, preso em janeiro deste ano, em menos de 90 dias já foi julgado em 1º grau.

Por outro lado, não é possível a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos notadamente pela quantidade de pena aplicada ao acusado e ainda pela reincidência específica.

Em razão de estar respondendo ao processo preso, tem-se entendido que seria um contrassenso libertá-lo após a sentença que a condenou. Ademais, remanescem presentes os requisitos da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Destarte, não poderá recorrer desta sentença em liberdade.

Recomende-se o réu na prisão em que se encontra, já que ainda persistem os motivos ensejadores da prisão cautelar, que deve ser mantida, notadamente, para a garantia da ordem pública, já que este delito é o que sustenta várias organizações criminosas que com o dinheiro adquirido com a venda de entorpecentes se armam cada vez mais e melhor para a prática de inúmeros delitos.

Por fim, em atenção ao determinado no art. 316, parágrafo único já com a nova redação, dou por revisada a prisão cautelar do acusado que deve ser mantida pelas razões acima expostas.

Após o trânsito em julgado, expeça-se guia de execução definitiva, e elabore-se o cálculo da pena da multa imposta ao réu, que fica desde já homologado, salvo se houver impugnação de alguma das partes.

Com a juntada dos cálculos aos autos, abra-se vista às partes para ciência e eventual manifestação.

Oficiem-se aos IIRGD e o TRE.

Custas na forma da lei, ressalvado o previsto no art. 98, §3º do Código de Processo Civil, que expressamente revogou o art. 12 da Lei 1.060/50.

P.R.I.C.

São Paulo, 20 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA